

1500707-34.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... para passar a limpo anotações do tráfico e que naquele dia alguns rapazes que são do tráfico de drogas haviam deixado uma bolsa lá. Foram verificar e encontraram uma certa quantidade de drogas, ela tinha R\$ 250. Fizemos uma varredura na viela, localizaram um revólver que estava abandonado dentro do mato, que provavelmente não tem relação nenhuma com a ré porque estava solta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500707-34.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500707-34.2020.8.26.0537 - Controle n. 2020/000705

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANA SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

ADRIANA SILVA DOS SANTOS, qualificada à fl. 15, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 17h30, na Passagem Bandeirante Garcia Pais nº 50, Canhema, nesta cidade e Comarca de Diadema, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 678 porções de cocaína, com peso de 386,93g., e 734 porções de cannabis sativa L, pesando 2,269kg., substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Dispensada a realização de audiência de custódia, conforme comunicado editado em 17/03/2020, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, como forma de reduzir a disseminação da COVID-19. Concedida liberdade provisória. (fls. 58/59). Notificada (fls. 95), apresentou defesa prévia às fls. 119/120. A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fl. 121). Citada (fls. 191), realizou-se audiência de instrução e julgamento, de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas policiais, interrogou-se a ré e procedeu-se com a gravação dos debates orais entre a acusação e a defesa. Em alegações finais, a D. Promotoria de Justiça requereu procedência do pedido, condenando-se a ré nos termos da denúncia, sob o argumento de que embora a ré tenha dito que os policiais forçaram entrada na residência é certo que não há efetivamente a comprovação de tal fato, sendo que ela mesmo admitiu que recepcionou

os policiais militares e apontou pra eles o local onde a droga se encontrava guardada. Mesmo que os policiais tenham forçado a entrada no imóvel, fizeram no estrito cumprimento de seu dever legal, tanto que a própria ré não disse em momento algum ter sido molestada ou maltarada pelos policiais, e a eles admitiu prontamente os fatos indicados a ela na denúncia. Assim, devidamente configurada a prática dos fatos imputados na denúncia, requer e aguarda a condenação da ré como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, não havendo como se falar em concessão dos benefícios do § 4º do artigo 33, não somente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, também porque a ré é reincidente, circunstância essa que deverá também ensejar a aplicação de um regime mais gravoso inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A D. Defesa, por sua vez, postulou a absolvição da ré, sob com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em conta que o encontro da droga decorreu de prova ilícita já que em violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, donde se afirma que restaram inviolados os artigos 157 do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal. Destacou que não houve consentimento da moradora para ingresso da polícia em sua residência, e nessa medida o ingresso foi irregular e ilegal, sendo ilegais todas as providências que a eles se seguiram, inclusive a apreensão da droga, que não se contesta tenha ocorrido, entretanto a apreensão foi em decorrência da ilegalidade primeiro do ingresso em domicílio e considerando a teoria do fruto da árvore envenenada é preciso reconhecer que tudo aquilo que se seguiu como linha de consequência e causalidade a esse ilegal ingresso está inclinado também à ilegalidade por consequência. Ressalta que no julgamento HC 598.051, julgado em 02/03/2021, o STJ fixou standard probatório para ingresso do domicílio do suspeito sem mandado judicial, esse standard probatório foi definido também em consonância com as orientações que foram estipuladas em sede de recurso extraordinário 603.616 no âmbito do Supremo Tribunal Federal em que se fixou tema em repercussão geral nº 280 estipulando a regras do standard probatório que para que seja autorizado o ingresso no domicílio primeiro é preciso que existam fundadas razões e justa causa. Sustenta que não havia urgência até porque na própria Lei de Drogas existem previsões que autorizam a postergação do flagrante para que eventualmente a polícia angarie mais elementos para configuração do delito, portanto na hipótese dos autos era cabível e devido a obtenção do mandado. Outro elemento do standard probatório identificado no HC 598.051 é o consentimento do morador, que deve ser voluntário e livre de qualquer constrangimento e coação e no caso dos autos não houve consentimento da moradora Adriana, que inclusive acordou com sua porta sendo quebrada. Ainda que houvesse confirmado a autorização para entrada dos policiais, seria o caso de reconhecer a falta de voluntariedade da conduta. Ainda sobre a questão do consentimento do morador, falasse que a prova da voluntariedade do consentimento do morador não é ônus da defesa e sim ônus estatal. Alguns meios de prova poderiam a posteriori confirmar a legalidade do ingresso sem mandado. O que se constata é que os policiais não observaram nenhuma dessas cautelas. A regra maior violada foi a que consta no Código de Processo Penal, e tem validade erga omnes, segundo a qual o ingresso na residência tem que ser precedido de mandado de busca quando esse mandado é viável, como era na hipótese dos autos e que a inviabilidade teria que ser justificada. Por isso, tendo havido violação a todas essas regras existe patente nos autos a ilicitude das provas obtidas em decorrência desse ingresso irregular e de todas as que dela decorreram em relação de causalidade; A defesa requereu a decretação de absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, e por violação expressa do artigo 157 do Código de Processo Penal e ao artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal, desde agora pré-questionados para fins de eventuais recursos nos Tribunais Superiores. Caso não seja acolhido o pleito absolutório, requer segundo pleito absolutório decorrente de estado de necessidade, pois Adriana se viu em estado de necessidade em razão da falta de gás, o que retira a ilicitude de sua conduta, pois o sacrifício desse bem implicaria provavelmente na perda de saúde de seus filhos. Diante disso, requer-se absolvição, de forma subsidiária, com fundamento no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal. Caso não seja este

o entendimento, quanto à dosimetria, requereu que a pena seja fixada em patamar mínimo, levando em conta as favoráveis circunstâncias judiciais e levando em conta a maneira sincera como a ré se manifestou em audiência. Na segunda fase requereu a aplicação da circunstância atenuante da confissão. Requereu excepcionalmente a aplicação do redutor legal do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, Reconhecido o redutor legal, requer seja aplicado o redutor na sua fração máxima, e seja estipulado o regime aberto em caso de necessidade de pena segregativa e eventual pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritivas de direito. Sem prejuízo, requereu que seja concedido direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Presente nulidade processual a ensejar a absolvição da ré.

Isso porque, houve violação do direito constitucionalmente previsto da inviolabilidade do domicílio, pois, ao que se constata, principalmente diante da prova oral produzida em juízo, houve ilegalidade na busca domiciliar precedida pelos agentes policiais, na ocasião dos fatos.

Assim, embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), do laudo de constatação (fls. 29/31), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 131/133) e do comprovante de depósito (fls. 150), todas essas provas são derivadas da violação domiciliar, portanto, inadmissíveis no processo penal, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

É o que se verifica da prova oral produzida em juízo. Senão vejamos.

Interrogada em juízo, a ré informou que atualmente não trabalha, faz bico na campanha eleitoral. Irão pagar R\$ 900 para trabalhar por trinta dias. Tem três filhos que moram com ela, Aline de 14, Guilherme de 8, e Gabi vai fazer 5 anos. Confessou a autoria delitiva. Guardou a sacola exatamente naquele dia, como foi denunciada, não sabe se alguém viu os meninos trazerem.. Acordou com os policiais entrando em sua casa de forma violenta, tanto que a sua porta está da mesma forma até hoje, quebrada. Na verdade, não saiu lá fora, da forma que estava dormindo, eles a acordaram. Levantou assustada porque o filho começou a chorar e foi ver o que estava acontecendo. Eles já estavam dentro na cozinha e entrando em seu quarto. Tentou conversar e explicar pra eles, e eles não quiseram ouvir. Entregou a sacola, não sabia a quantidade e ao certo o que tinha só pegou e guardou. Do jeito que estava a sacola os policiais levaram. A sacola foi entregue no mesmo dia por volta das 14h30 ou 14h40 da tarde. Por volta de 17h ou 17h30 foi quando os policiais entraram. Berê entregou a sacola e pediu pra guardar pra ele que mais tarde alguém viria buscar. Os policiais vieram já com sua foto na mão, dizendo que foi uma denúncia anônima e que viram os rapazes vindo até sua casa para entregar a sacola. Não sabia certo quem o rapaz era, ele não era de onde ela mora, simplesmente ele estava lá no escadão. Na época, havia perdido o emprego por conta da pandemia, ficou sem o gás e foi pedir dinheiro pra eles, falou que sabia que doavam cesta básica e no caso dela precisava de um gás. Depois disso falaram que não precisaria pagar e quando tivesse necessidade devido às crianças poderia procurá-los que poderiam ajudar com cesta básica ou algum alimento, em troca disso ela poderia passar a limpo algumas anotações que eles iriam trazer. Inicialmente, deram 180 e, na segunda semana, iriam pagar o valor de R\$ 200. As anotações que estavam no caderno foi ela que passou a limpo, os papéis pequeninhos guardava para que eles confirmassem as anotações. Esse pessoal do escadão seria a biqueira onde vende as drogas. Acordou com a policia dentro de sua cozinha. Eles entraram de forma que sua porta ficou do mesmo jeito até hoje. Entraram e o filho começou a chorar porque estranhou cinco pessoas diferentes dentro da casa. Levantou e foi lá fora conversar com eles. Os policiais a puxaram para o quarto de sua filha, colocaram armas, falaram que iam agredir, porém não o fizeram. Só queriam saber onde estava a droga. Na delegacia, falaram para o delegado que encontraram arma na viela onde ela mora. Quando Berê deixou as drogas, ela já sabia que eram entorpecentes, ela pediu que tirasse o mais rápido possível, mas ele não veio buscar. Após ser levada para delegacia, eles sumiram. Os policiais levaram seu telefone. Guardou a sacola do

jeito que as entregaram, não mexeu em nada. Ele deixou de uma forma rápida que acha que já sabia que tinha polícia, mas não a avisou, só pediu pra guardar e ela guardou. Ficou assim de falar não, porque não ia brigar com essas pessoas. Da mesma forma que lhe entregaram, entregou nas mãos dos policiais. Está aguardando sobre sua situação policial. Nunca a chamaram no fórum para nada sobre o processo da moto. Tem um estelionato anterior. Na primeira vez que foram no fórum pediram pra assinar uma carteirinha e pagar multa. Estava desempregada e grávida, não conseguiu finalizar, mas nunca mais a chamaram nem falaram nada. Quando o oficial de justiça foi a sua casa, ele perguntou mas não soube responder. Não voltou a se envolver com o pessoal. Como a porta é de alumínio quando os policiais entraram fez um estrondo, um eco dentro de casa, no dia seguinte viu que estava tudo quebrado. Sua casa tem apenas uma entrada, não tem fundo, não tem nada. Questionada pela defesa para mostrar a porta, se dirigiu até a porta de entrada da casa. Disse que porta é de alumínio, essa parte em que está o vão foi onde foi estourado na hora em que eles entraram. Onde está o vão foi onde saíram as lâminas e colocou algumas madeiras porque de noite entra muito frio pra dentro de casa. Até hoje não conseguiu trocar a porta porque tem pagar o pedreiro e comprar outra porta, então fica mantendo dessa forma. Quebrou a fechadura, mas como tem outro portão, coloca o cadeado e ninguém entra. Questionada pela defesa se as adaptações que teve que fazer foram em decorrência da quebra da porta pelos policiais, respondeu que sim. Na época não falou nada porque tudo que falasse os policiais iriam pra cima dizendo que iriam bater e não falou nada, ficou calma por causa dos filhos, pra passar pra eles mais calma.

O depoimento da ré, ademais, foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, pois, a ré logrou em demonstrar, em audiência telepresencial, por meio de vídeo, os danos que narrou terem sido feitos na porta de sua residência, na data dos fatos, após entrada forçada dos policiais.

Com efeito, conforme se pode verificar pelo vídeo da audiência acostado aos autos (fl. 195 - a partir do minuto 24:57), na porta da casa, o espaço em que deveriam haver vidros, teve que ser tapado com peças de madeira e a porta está sem fechadura, só sendo possível trancar a residência por meio de cadeado, que é colocado no portão que fica a frente da porta danificada. Segundo declarado pela ré em depoimento, a porta não estava nesse estado antes da data dos fatos, tendo notado os danos apenas no dia seguinte após o ocorrido.

Por outro lado, em depoimento prestado a este juízo, a testemunha Flávio Soares de Sousa, policial militar, afirmou que recebeu a informação pelo Dique Denúncia de que uma mulher chamada Adriana estaria armazenando drogas em sua casa. Realizaram a diligência até a casa de Adriana. Ela mesmo atendeu e ficou muito nervosa, já dava pra ver que havia alguma coisa que estava diferente. Ela colaborou e disse que recebia algumas folhas e recebia dinheiro para fazer a transcrição, para passar a limpo anotações do tráfico e que naquele dia alguns rapazes que são do tráfico de drogas haviam deixado uma bolsa lá. Foram verificar e encontraram uma certa quantidade de drogas, ela tinha R\$ 250. Fizemos uma varredura na viela, localizaram um revólver que estava abandonado dentro do mato, que provavelmente não tem relação nenhuma com a ré porque estava solta no beco. Na delegacia, o delegado disse que conversou com ela, que ela disse que recebia cerca de R\$ 200 por semana pra fazer a transcrição das anotações do tráfico e falou que um rapaz de vulgo Berê havia contratado ela pra essa função de passar a limpo e que as drogas estavam na casa dela porque aquele dia alguns rapazes pediram pra ela guardar dentro da residência dela. As drogas foram encontradas dentro da casa, não se lembra o local exato, a ré mesmo que apresentou as drogas, estava bem tranquila e colaborou com a polícia. Indagamos e ela disse que eles deixaram aquela bolsa e nos levou e mostrou. Quando abriram tinha droga. Não recorda o cômodo da casa em que a bolsa foi encontrada. Não conhecia a ré antes dos fatos.

Ainda, a testemunha Carlos Alberto de Oliveira Simpliciano Filho, também policial militar, narrou que, após denúncia, deslocaram-se ao local. A denúncia dizia que a senhora Adriana guardava em sua residência entorpecentes. Na residência, foram atendidos pela senhora Adriana, ela mesmo de pronto os levou ao local onde estava a sacola com a droga e informou que quem havia deixado a sacola eram uns meninos ali

do local, de vulgo Berê. Foram também localizadas algumas folhas constando a contabilidade da venda de drogas e uma quantia em dinheiro. Em local próximo, foi localizado armamento. Se lembra vagamente que foram localizados cocaína e maconha, cerca de 700g. de cocaína e algo em torno de 2kg. de maconha, tudo separado e pronto para venda. O entorpecente estava no quarto, a casa era pequena, a ré os levou até o quarto onde estava a sacola. Quando solicitaram a entrada, ela autorizou entrou junto com eles, mostrou onde estava a sacola com os entorpecentes. Após isso, os policiais ficaram com ela enquanto outros integrantes do pelotão, fizeram busca ao redor da casa foi sim. Nunca havia visto a ré antes dos fatos. Verifica-se, portanto, a presença de contradições entre a versão dos fatos apresentada pela ré e as versões apresentadas pelos policiais militares.

Embora a credibilidade do testemunho dos policiais não possa ser afastada, fato é que o interrogatório da ré, quando somado as imagens produzidas em audiência, são capazes de gerar dúvida razoável acerca da legalidade da diligência efetuada pelos policiais, o que por si só, seria capaz de ensejar a absolvição da ré, diante a aplicação do princípio jurídico in dubio pro réu.

No caso dos autos, segundo consta dos depoimentos dos policiais, estes tomaram conhecimento do depósito das drogas via Disque Denúncia, sem esclarecer com clareza quem a recebeu, como foi recebida, qual era o teor integral da informação, ou outros elementos capazes de ensejar fundada suspeita de que naquele local realmente havia depósito de drogas. Sendo certo que, a providência correta a ser adotada, seria o repasse dessas informações à policial civil, para então, após investigação, ser solicitado judicialmente mandado para a busca e apreensão no domicílio da ré. Ademais, em nenhum momento os policiais responsáveis pela diligência mencionaram que a informação repassada pelo Disque Denúncia indicaria que a droga estaria sendo deslocada ou que se estaria realizando a comercialização no referido endereço, de modo que se justificasse tamanha urgência que inviabilizasse a espera por autorização judicial para ingresso no domicílio.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido que mera denúncia anônima, desacompanha de outros elementos que indiquem a real possibilidade de atividade criminosa, não é suficiente para ensejar o ingresso no domicílio alheio: "AUSÊNCIA DE MANDADO E DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. REALIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas e de posse de arma de fogo e munições, o estado de flagrância se protraía ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio. 2. Recurso especial improvido." (STJ - REsp 1708029/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/02/2018, DJE 03/04/2018)(grifos).

Ainda, nesse mesmo sentido há a tese nº 280 do Supremo Tribunal Federal, a qual foi reconhecida como tema de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." Outrossim, também deve ser afastada a hipótese permissiva constitucional de que teria havido consentimento da moradora para o ingresso, pois, os policiais não foram uníssonos e claros ao descrever como teria ocorrido o consentimento da ré para que eles adentrassem ao imóvel, ao contrário, mostraram narrativas vagas nesse sentido. A ré, por outro lado, além de negar que tenha consentido, fez prova de que sua porta estava quebrada, afirmando ser em decorrência da entrada forçada e violenta da polícia, conforme se verifica do depoimento e imagens colhidas em audiência virtual.

Portanto, apesar de realmente terem sido localizadas drogas no interior da residência, ao se reconhecer que houve a entrada forçada pelos policiais sem a salvaguarda de mandado judicial autorizativo, e, ainda, sem a justa causa que se

enquadrasse em flagrante delito ou consentimento expresse de morador, é imperativo reconhecer a ilegalidade da conduta por violação do domicílio, e, por consequência, forçoso reconhecer a ilegalidade de todas as provas produzidas em decorrência da violação do domicílio.

Assim, inexistindo nos autos outras provas que não as derivadas do ato considerado ilegal e, portanto, nulo, não há outra solução que não a absolvição da ré, por insuficiência de provas.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, ABSOLVO ADRIANA SILVA DOS SANTOS, da acusação de infração do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas pelo Estado.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que na decisão de fls. 58/60 já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Determino a destruição da sacola e das folhas de caderno apreendidas (fls. 12/13), pois não têm valor comercial. Quanto aos R\$ 250,00 apreendidos (depósito à fl. 150), considerando a absolvição, determino sua devolução à ré.

Anoto que já foi conferida destinação à arma e munições apreendidas (fl. 76/77). Autos conclusos para sentença, intuem-se as partes. Façam as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA